Cópia Impressa

quinta-feira, 15 de outubro de 2026 21:39

15 de outubro de 2026

jusbrasil.com.br

Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo. Acesse:
https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

instituto da pensão avoenga: uma abordagem sobre a inclusão do avós maternos e paternos no polo passivo da ação de alimentos.

INSTITUTO DA PENSÃO AVOENGA: UMA ABORDAGEM SOBRE A INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS E PATERNOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ALIMENTOS

RESUMO

Esse artigo científico aborda o instituto da pensão alimentar em face dos avós, enfatizando a obrigação conjunta dos avôs paternos e maternos pela prestação alimentícia aos netos, na hipótese de ausência ou impossibilidade dos genitores em prestá-la. Além do mais, faz uma abordagem sobre a parte histórica do direito alimentar, e a sua devida evolução. Descrevendo a natureza da obrigação alimentar e o dever dos genitores e avós na prestação da pensão alimentícia, demostrado através da leitura do artigo nº 1696 do código civil, e artigo nº 227 da constituição federal. Abordando a inclusão no ordenamento jurídico brasileiro da Lei Federal nº 11.804, 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre alimentos gravídicos, bem como elementos da pensão avoenga. De forma específica, analisa-se o artigo nº 1698 do código civil, e a possibilidade de diluir entre avós paternos e maternos a obrigação alimentar, quando estendida aos mesmos, perfazendo a formação litisconsorcial de natureza necessária. Apontando como Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais estaduais vem se posicionando a respeito.

Palavras-chave: Alimentos avoengos. Obrigação conjunta. Litisconsórcio. Avós paternos e maternos.

ABSTRACT

This scientific article addresses the alimony institute vis-à-vis grandparents, emphasizing the joint obligation of paternal and maternal grandparents to provide food for their grandchildren, in the event of the absence or impossibility of parents to provide it. Furthermore, it addresses the historical part of the right to food, and its evolution. Describing the nature of the maintenance obligation and the duty of parents and grandparents to provide child support, shown by reading article 1696 of the Civil Code, and article 227 of the Federal Constitution. Addressing the inclusion in the Brazilian legal system of Federal Law No. 11,804, November 5, 2008, which provides for pregnant foods, as well as elements of the grandparent's pension. Specifically, the possibility of diluting the maintenance obligation between paternal and maternal grandparents, when extended to them, is analyzed, based on the provisions of article 1698 of the Civil Code, making the necessary litisconsorcial formation, based on decisions on the topic handed down by the Superior Court of Justice and the state courts of law.

Key words: Avoengos foods. Joint obligation. Litisconsortium. Paternal and maternal grandparents.

INTRODUÇÃO

A formação da sociedade sempre esteve ligada ao vinculo familiar que em regra é formado por um homem, uma mulher e um filho, que desde o seu nascimento vai criar laços com seus genitores que perpetuam por toda vida, claro que há de se esperar que esses laços sejam criados das melhores formas possíveis, onde a criança seja devidamente amparada em todos os sentidos pelos seus genitores. Esse amparo de certo modo são obrigações que abrangem a educação, a saúde e a alimentação, proporcionando um crescimento adequado para o menor. Trata-se de um dever dos genitores em prol dos seus filhos. Esse direito decorre da premissa, de que os filhos, até alcançar a sua independência, são incapazes de prover seu próprio sustento.

Desta feita, vai ser analisado o real dever dos pais no dever de sustento dos seus filhos, que foi legalmente disciplinada pela lei 5.478/68, e teve um reforço com o advento da Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002. Nesse contexto, a obrigação dos avos, de caráter subsidiário, deve apenas ser instituída na comprovação fática de que os genitores não possuem qualquer condição de arcar com o devido encargo.

Ademais, busca-se analisar o Código Civil de 2002, no art. 1698, ao afirmar que na impossibilidade total do parente principal em arcar com a referida obrigação alimentar

poderão ser chamados os parentes de grau mais próximos, que na maioria dos casos são os avós. Portanto, serão explicados os efeitos processuais causados, devido ao verbo "poderão" visto que esse termo usado gera uma confusão na parte processual.

Assim, esse estudo vai analisar os efeitos do artigo acima mencionado, a quem o genitor ou genitora vai propor a ação, se em face dos avós diretamente, ou primeiro interpor contra o genitor, e comprovada sua impossibilidade, será chamado para compor a ação apenas os avós paternos ou ambos os avós, paternos e maternos, ou se na inicial deve-se interpor diretamente a ação contra os avós.

Será objeto de averiguação, também, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça do Brasil e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acerca do litisconsórcio nesse tipo de ação, se é de natureza facultativa ou necessária.

Deste modo, será analisado o dever dos pais em fornecer a pensão alimentícia para seus filhos, o quão isso é importante para a ocorrência de um crescimento justo e digno do menor, ressaltando também o quão é importante à inclusão dos avos no polo passivo da ação, e quais os requisitos que permitem que os mesmos sejam responsabilizados.

O principal objetivo é falar do instituto da pensão avoenga, que é quando a obrigação alimentar recai sobre os avós, que de acordo com a doutrina e jurisprudência brasileira é perfeitamente cabível quando ocorrer uma impossibilidade dos principais alimentantes. O Código Civil de 2002 no art. 1696 diz que no impedimento dos pais, esse dever é estendido a todos os ascendentes, respeitando o grau mais próximo de parentesco. Tudo isso para garantir que nenhum parente fique sem o devido auxilio.

1 RESGATE HISTÓRICO DO DIREITO ALIMENTAR

A prestação alimentar, assim como qualquer instituto do direito, teve sua evolução no decorrer da história. Na Roma antiga essa obrigação era disciplinada e imposta por vários motivos, convenção no testamento, relação de patronato. Observa-se que só posteriormente esse encargo passou a integrar as relações que decorrem do vínculo de parentesco, pois ainda era vista como um dever moral que era imposto ao chefe da família, nota-se que nesse período não havia uma ideia ou conceito do que seriam os alimentos.

Nessa vertente, os filhos sequer gozavam dos direitos em relação ao patrimônio, como leciona Àurea Pimentel Pereira:

Nos primórdios da civilização romana a palavra família, ora era usada para designar a reunião de pessoas unidas por parentesco civil (agnatio), que viviam sobre a pátria potestas, nelas incluídas a mulher e os filhos, ora para abranger, além daquelas pessoas, os escravos e o próprio patrimônio do pater, que tinha a autoridade diretiva da família (1988, p. 345).

Yussef Said Cahali enunciou que não tem como saber quando a obrigação alimentar no Direito Romano passou a ser reconhecida com base no princípio da solidariedade familiar, mas que a parti do momento em que houve o avanço no sentido de reconhecer o vínculo de sangue que é estabelecido entre os membros da família, esse direito passou a ter uma maior visibilidade e transformação (CAHALI, 2009. p. 42). Nesse sentido, ‘’Clóvis Beviláqua expõe que o direito romano prescreveu a obrigação alimentar, reciprocamente, entre ascendentes e descendentes, inclusive entre a mãe e filho ilegítimo’’ (MALUF, 2013. p. 673).

Assim, nota-se a evolução da obrigação alimentar no direito romano, que antes era vista de uma forma não especifica, tratando até mesmo como uma mera ajuda, mas o direito evolui de acordo com a evolução da sociedade, e junto com essa evolução, foi amparada a ideia de que houvesse a inclusão da solidariedade nas relações de parentesco, tornando possível que o descendente tenha direito a receber os alimentos de seu genitor.

O direito canônico deu um grande passo na prestação alimentar estabelecendo a solidariedade entre os familiares e até mesmo nas extrafamiliares, abrangendo os filhos espúrios, esse seriam aqueles filhos concebidos fora do casamento, também abrangeu os asilado que eram socorridos na igreja, e ainda foi levantada a hipótese de que a obrigação alimentar poderia ser pertinente entre tios e sobrinhos ou padrinhos e afilhados (MALUF, 2013. p. 673).

Os alimentos passaram a ter várias intepretações ao longo da história, e nesse contexto evolutivo, foi sendo fixada a ideia de que para serve a prestação alimentar. Javoleno dizia que os alimentos representam o sustento, as vestes e a moradia do indivíduo, e sem essas coisas o ser humano não consegue se manter (VILLAÇA, 2013, p. 333). O seu devido fim é sempre abranger tudo aquilo que for necessário para que o alimentado tenha uma vida digna.

Nesse pensamento, Madaleno, (2013, p. 333):

Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito a vida e representam um dever de amparo dos parentes, cônjuges e conviventes, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação social e econômica desfavorável.

No Brasil, ainda sob a égide da colônia portuguesa, um rol de diplomas legais que tinha uma influência do Direito Romano, podendo se dizer que o Direito de família já estava propenso à obrigação alimentar, por exemplo, o Código Civil de 1916 em entendimento com a Constituição de 1891, abrangeu a obrigação alimentar em vários pontos, em seu artigo 231 estabeleceu que os cônjuges tem o dever de mútua assistência, no artigo 396 desse mesmo código, finalmente foi estabelecido a capacidade de uma parente exigir uns dos outros a pensão alimentar, para que seja necessária a sua própria subsistência, e também a reciprocidade entre pais e filhos.

Verifica-se uma série de vantagens com o advento do Código Civil de 1916, mais ainda tinha alguns retrocessos que só teriam uma mudança com leis especificas promulgadas alguns anos depois, exemplificando, o código vigente na época ainda tinha vestígios patriarcais, sendo o homem o chefe da família e responsável pela aquela união conjugal.

Dias, (2011, p. 2014):

Como o casamento não se dissolvia, mantinha-se o encargo assistencial, ao mesmo do homem para com a mulher, a depender da sua inocência e necessidade, assim reconhecida na ação de desquite. O dever de sustento somente cessava no caso de abandono do lar sem justo motivo. A preocupação não era com a necessidade, mas com a conduta moral da mulher.

Mas a importância do Código Civil de 1916, foi que, varias legislações passaram a surgir e abranger de uma forma mais especifica a pensão alimentícia, o Decreto Lei nº 3.200 de 1941 (Lei de Proteção à Família) que instituiu que no caso de o pagamento da pensão não estiver sendo cumprido, poderá a requerimento do interessado que seja realizado o desconto em folha de pagamento, Lei nº 883 de 1.949, que permitiu o reconhecimento dos filhos concebidos fora do matrimonio, mas foi revogada pela Lei nº 12.004 de 2.012, que trouxe outro grande avanço, ao afirmar que na recusa a fazer o teste de DNA, presume que o suposto genitor que recusou, é de fato o pai da criança.

Em 1968, surgiu a legislação mais lembrada, a Lei nº 5.478 de 1968, que dispõe sobre a ação de alimentos. Apesar das devidas mudanças no campo processual, essa lei ainda é muito utilizada por aqueles que necessitam da pensão alimentícia, foi uma lei muito importante, trazendo um rito especial para esse tipo de ação, e estabelecendo a possibilidade da fixação dos alimentos provisórios, deste modo, pode-se afirmar que essa lei trouxe mudanças positivas nesse instituto.

Quase um século após a promulgação do Código Civil de 1916, em 2002, surgiu o Novo Código Civil, trazendo uma série de inovações e mudanças na seara dos alimentos. Introduziu, em seu art. 1.694, a possibilidade de cônjuges e outros parentes pedirem alimentos uns aos outros, claro que no caso do cônjuge, cabe essa fixação, quando o mesmo não tenha aptidão para o trabalho. Deste modo, pode-se dizer que o novo Código Civil não faz distinção sobre o fato que originou a obrigação alimentar, ou seja, não interessa se decorreu do poder familiar, rompimento do casamento, importa apenas o direito à vida digna do indivíduo que necessita dessa prestação.

Nesse rumo, o direito aos alimentos era tratado como um dever moral, mais levando em consideração a dignidade da pessoa humana e solidariedade, previsto na Constituição Federal de 1988, que teve a família como base da sociedade brasileira regulando, em seu art. 226, o dever de solidariedade entre os familiares. Assim, a criança ou adolescente tem o direito de ser alimentada em razão de parentesco com os pais, que tem o dever de alimentá-la. Assim, percebe-se que toda essa evolução na obrigação alimentar trouxe mudanças significativas, trazendo legislações que com o passar dos anos passaram abordar esse instituto de diversas maneiras, até chegamos ao momento atual, onde é praticamente absoluto o dever de alimentar e amparar os filhos.

2 ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

Todo instituto, no mundo jurídico, é objeto de estudo questionamentos, legislações e por último as suas características. No caso da pensão alimentar, é claro que não seria diferente, pois esse instituto é repleto de características próprias, que vão ser delineadas a seguir:

Direito personalíssimo, sabe-se que esse direito aos alimentos não é de qualquer um, o titular desse direito é único, ou seja, só aquele que tenha uma relação de vinculo parentesco com o devedor pode pleitear pelos alimentos. Nessa vertente, Dias (2014, p. 516) afirma:

O direito a alimentos não pode ser transferido a outrem, na medida em que visa a preservar a vida e assegurar a existência do indivíduo que necessita de auxílio para sobreviver em decorrência direta de seu caráter personalíssimo, é direito que não pode ser objeto de cessão.

Então apenas o credor pode receber a pensão alimentar, e não pode em nenhuma hipótese transmitir esse direito, pois não se trata de uma dívida comum, onde é possível a transmissão do credito, pelo contrário os alimentos tem um fim específico, que é assegurar o bem do alimentante.

Divisibilidade: trata-se da premissa de que havendo vários sujeitos, que estejam no mesmo grau de parentesco todos devem responder e arca com sua parte, isso quer dizer que pode os alimentos ser fracionados, essa inovação foi delineada no art. 1.698 do Código Civil de 2.002, que ao manifestar que no caso de várias pessoas obrigadas a prestarem com os alimentos, esse débito vai ser dividido entre elas. Devido a essa possibilidade, ‘’afasta-se’’ a possibilidade de ser uma obrigação solidária. Dias (2014, p. 517) assim diz:

Pacificaram-se doutrina e jurisprudência, entendendo que o dever de prestar alimentos não era solidário, mas subsidiário e de caráter complementar, pois condicionado as possibilidades de cada um dos obrigados. Sua natureza divisível sempre serviu de justificativa para reconhecer de que não se trata de obrigação solidária.

Claro que, a fala acima não é absoluta, visto que o a Lei 10.741 (Estatuto do Idoso) afirma que o dever de amparar o idoso é de natureza solidária, ou seja, o idoso pode escolher quem deve lhe prestar os alimentos. Assim, havendo mais de um filho, os idosos, podem acionar somente um dos filhos (MADALENO, 2020, p. 363). Então, nesse caso, não incide a hipótese de um litisconsórcio necessário.

A reciprocidade trata-se do dever de alguém ter com outrem, no campo dos alimentos, esse elemento, em regra decorre com vínculo de parentesco, seja na forma sanguínea, ou na forma de afetuosa, que é no caso da obrigação entre os cônjuges, companheiros.

Nessa linha, aponta, Rolf, (2019, p. 938):

A reciprocidade não significa que duas pessoas devam alimentos entre si, mas tão somente que o devedor de hoje poderá ser o credor do futuro e tampouco se confunde com a reciprocidade das obrigações bilaterais derivadas de um contrato sinalagmático,

onde ambos são credores e devedores ao mesmo tempo, pois é impossível em uma relação alimentícia, que ao mesmo tempo recaia sobre as mesmas pessoas um dever e um direito de alimentos, pois entra em jogo a situação de necessidade de quem ocupa a posição de credor e a condição de possibilidade daquele que se vê obrigado a prestar os alimentos.

Deste modo, percebe-se que junto com o vínculo familiar, nasce a obrigação recíproca dos pais em manter seus filhos, podendo ser estendida aos parentes de grau mais próximos, e se no futuro os genitores precisarem do auxilio alimentar, pode pedir aos seus filhos, então é uma via de mão dupla, hoje você é o alimentante, amanhã pode ser o alimentado.

Transmissibilidade: essa característica já estava presente em nosso ordenamento antes mesmo da vigência do atual Código Civil, a Lei 6.515 (Lei do Divórcio) fixou essa hipótese em seu art. 23, afirmando ser possível a transmissão dos alimentos aos herdeiros do alimentante, o atual código estabeleceu essa possibilidade no seu art. 1.700.

Essa característica visa garantir que o alimentado não fique desamparado, mais também garante a possibilidade do novo credor da dívida. O atual Código, no art. 1694, afirma que os alimentos devem ser fixados com base nos recursos da pessoa obrigada, pois deve ser averiguada a possibilidade e necessidade do herdeiro.

A grande questão dessa característica é saber se o pagamento após o falecimento do alimentante vai ser realizado de acordo com as rendas dos herdeiros. O art. 1.792 do Código Civil afirma que o herdeiro não responde por dívidas superiores até o limite da herança, então o herdeiro não vai se preocupar com os seus bens, somente com os bens do falecido que pagará o que for devido.

A irrenunciabilidade, que dizer que o credor dos alimentos não pode transferir o seu credito, logo é inadmissível a renúncia, pois o art. 1.707 do código civil diz que lhe é vedado renuncia o direito a alimentos.

Analisando esse dispositivo, é plausível que não permita que o credor abra mão do seu direito de receber os alimentos, pois esse direito está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, outro ponto, é que se não houvesse a disposição legal proibindo a renúncia esse direito entraria no mercado, onde pessoas iriam negociar os créditos alimentares, e até mesmo transferir ou realizar uma permuta.

Concluindo, quando tratamos da criança e adolescente, a primeira conclusão é de que aquela ou aquele menor está numa situação de "vulnerabilidade" não tem capacidade mínima de prover seu sustento, então para que o alimentado não seja coagido ou até mesmo ludibriado a abrir mão dos alimentos, é de suma importância a irrenunciabilidade da pensão alimentícia, visto que esse direito representa muito mais que uma mera quantia em dinheiro.

Imprescritibilidade, a parti do momento que um direito é violado, nasce o direito de ação, que em regra está nas mãos do lesionado, que através de um advogado, vai judicialmente procurar o Estado juiz para requerer aquilo que lhe convém, ocorre que o titular da ação em regra tem um prazo para pleitear o seu direito, que é chamado de prazo prescricional.

Mas na obrigação alimentar, em regra não existe esse prazo, salvo quando os alimentos devidos não pagos, no prazo de 02 (dois) anos, conforme o art. 206 do Código Civil, prazo que começa a contar a parti da data em que há o vencimento da dívida, o credor pode a qualquer momento exercer o seu direito de pedir os alimentos (LUZ, 2009, p. 295).

Mas quando se trata do direito de incapazes, não transcorre a prescrição, podendo o credor exigir o pagamento da pensão em qualquer tempo, pois a necessidade do alimentado é de uma natureza contínua. Exemplificando essa fala: o credor que precisa dos alimentos para prover seu sustento mínimo, em regra, até obter capacidade para se sustentar, a sua necessidade não vai deixar e existir.

Nesse entendimento, Madaleno (2019, p. 949).

É ensinamento que está de acordo com o pensamento também externado por Júlio J. López del Carril, quando diz que a imprescritibilidade dos alimentos se justifica pelo fato de a obrigação alimentícia se renovar diariamente, conforme também vão se renovando periodicamente as necessidades do credor, e como a prescrição deve ser computada desde o momento em que o direito se torna exigível ela jamais poderia ser definitivamente operada, porque a necessidade alimentar se renova a cada dia.

Impenhorabilidade: o art. 1.707 do Código Civil diz que o credor não pode renúncia os alimentos, e nem pode ser passível de transferência, logo não pode ser penhorado. Nas palavras de Rolf Madaleno, por ser um direito de caráter personalíssimo do alimentado,

e o mesmo não ter trabalho e consequentemente não possuir recurso próprio para prover seu sustento, não tem como permitir que seu crédito de natureza alimentar seja penhorado, como já dito anteriormente, os alimentos tem o devido fim de prover a existência da criança ou adolescente, e não há de seus credores. (Madaleno, 2019, p. 969).

Observando essa característica, percebe-se que há uma semelhança com a irrenunciabilidade. Ambas visam garantir que o credor use a pensão alimentar para o seu mantimento, provendo sua própria existência, afastando até, o uso de má fé desse direito, evitando que o credor, vise receber a pensão de com o fim intencional de pagar dívidas de trocar por outros favores e etc.

Incompensabilidade: o devedor de hoje pode ser o credor de amanhã, e isso pode acontecer na prestação alimentar, vamos supor, que hoje o alimentante é jovem é apropriado ao mercado de trabalho, consegue manter seu sustento e de seu dependente, sem dificuldade, mas daqui uns 20 (vinte) anos, adquiri alguma patologia, que gerou gastos não previstos na sua renda, o levando a vender alguns de seus bens, pedi empréstimos, e assim, acumulou dívidas de um valor exorbitante, que mal conseguem adimplir, e também não consegue manter seu sustento. Deste modo o seu dependente, que atualmente possui capacidade de manter seu sustento, pode se torna o devedor da obrigação alimentar, em virtude da solidariedade familiar.

Pode se afirmar que não há compensação na obrigação, simplesmente, o credor não deve obrigar o devedor a lhe compensar pelo tempo em que o forneceu a pensão alimentar, pois, o devedor não está prestando nenhum favor, pelo contrário, está cumprindo com um dever de sustento, explicito na constituição federal, e nas demais legislações.

Irrepetibilidade: os alimentos, uma vez que fornecidos, não haverá possibilidade do devedor ter direito de reembolso Yussef Said Cahali diz que ainda que não haja em nosso direito disposição semelhante à do art. 2.007, nº 2, do CC português, expresso no sentido de não alugar, em caso algum, à restituição dos alimentos provisórios recebidos, considera-se pacífica a jurisprudência dos tribunais aqui no Brasil, sobre a irrepetibilidade das pensões ou parcelas pagas pelo alimentante (TARTUCE, 2014 p. 493).

Ressalto a importância dessa característica, pois garante ao credor que a prestação alimentar que recebeu durante anos, é apenas sua, visando apenas assegurar seu mero

sustento, sem o temor de haver a possibilidade de num futuro, ter que ressarcir toda aquela quantia para o alimentante.

2.1 DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR: E O DEVER DOS GENITORES E AVÓS EM PRESTAR COM A PENSÃO ALIMENTICIA

Primeiramente há de se frisar, que a obrigação alimentar é de caráter transitório, tendo em regra sua natureza imposta pela legislação, que obriga genitor do menor a dar o mínimo necessário para que o mesmo tenha suas necessidades supridas. Pode-se afirmar que é um direito de caráter fundamental do alimentante, havendo de fato um interesse não só do menor, mas do próprio Estado democrático de Direito que tem a função de garantir e assegurar o bem-estar social de todos, assegurando uma vida digna e justa, denota, Madaleno (2020, p. 356):

Para Yussef Said Cahali, a obrigação alimentar está fundada sobre um interesse de natureza superior, detendo um caráter de ordem pública das normas disciplinadoras da obrigação legal de prestar alimentos, não se resumindo aos interesses privados do credor, mas, com atuação que respeita a uma faixa geral da sociedade, com destacado conteúdo ético pelo fato de as regras que o governam estarem relacionadas à integridade física e moral da pessoa, sua digna subsistência e personalidade, portanto, consubstanciando-se em direitos fundamentais da pessoa humana.

O dever dos pais em prestar com os alimentos tem um caráter irrenunciável, mas isso não é absoluto, pois é possível que o genitor deixe de dar pensão alimentícia, normalmente quando o filho atingi a maior idade, mas enquanto isso não acontece, em regra aquele que tem de arca com essa obrigação, não pode simplesmente abster-se do referido encargo, nas palavras de Farias (2010, p.715 - 716):

De regra, os alimentos devem recair, prioritamente, sobre os pais ou os filhos (parentes de linha reta, no primeiro grau). Entretanto, não havendo parente no primeiro grau na linha reta ou, caso exista, não tendo condições de atender a todas as necessidades básicas de quem pede os alimentos, admite-se que a cobrança seja dirigida aos parentes em graus subsequentes (avós e netos, bisavôs e bisnetos...), à luz da reciprocidade alimentar.

Não há questionamento de que aos alimentos destinados ao menor, devem ser de responsabilidade de seus genitores, recaindo apenas sobre outros parentes na sua total im-

possibilidade. Deste modo, com o advento da Constituição Federal de 1988, e logo após o Código Civil de 2002, a prestação da pensão alimentícia ganhou muito mais visibilidade, dando um ensejo maior ao instituto da obrigação alimentar. Nesse sentido, observa-se o disposto no art. 227 da Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

Há de se observar que o artigo supracitado é bem claro sobre o dever da família em assegurar a alimentação, a educação e lazer da criança ou adolescente, ou seja, a família à qual o artigo faz menção, em regra, deve ser os genitores, que tem a obrigação solidária de arcar com os alimentos aos seus próprios descendentes, que no caso são os filhos.

Nessa vereda, nota-se o binômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, ou seja, na fixação dos alimentos não deve pôr em risco o mínimo para alguém obter uma vida digna conforme os parâmetros constitucionais.

Claro que haverá casos em que o principal alimentante não vai cumprir com a obrigação alimentar, muitas das vezes pelo fato da sua real incapacidade financeira. Assim, o Código Civil, preocupado com essa possibilidade, positivou no artigo 1696 o seguinte, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

Analisando o referido artigo, nota-se que a obrigação alimentar vai além de um mero dever, é necessário uma reciprocidade, que é criada através da convivência, assim gerando, um vínculo e laços afetivos que normalmente irão perpetuar por toda vida, assim, não é plausível que o genitor que abandonou seu ascendente e nunca prestou com nenhuma obrigação, invoque a obrigação alimentar para que seu filho seja obrigado a dar os alimentos a seu favor (DIAS, 2014, p. 538). Mas essa reciprocidade não deve ser justificativa dos genitores para não cumprir com a obrigação alimentar, visto que nesse caso, trata-se de um dever, amparado pela Constituição Federal.

No entanto, observa-se que não há qualquer impedimento a respeito, da obrigação alimentar recair sobre os avós, tendo em vista que na incapacidade dos genitores, os avos

estão na linda de ascendência direta, essa obrigação tem uma relação com a solidariedade familiar, que nada mais é que o dever de um determinado membro da família em amparar o parente que esteja desamparado.

Nesse entendimento apresenta-se a súmula 596 do STJ, esta súmula afirma que a obrigação avoenga é de caráter subsidiário, e só deve ser instituída na incapacidade dos genitores. Portanto, não se deve confundir incapacidade com falta de vontade, visto que a incapacidade deve ser justificável assim corrobora Gonçalves, (2019, p. 549):

A incapacidade do principal obrigado pode consistir: a) na impossibilidade para o exercício de atividade laborativa decorrente de estado mórbido, por doença ou deficiência; b) na reconhecida velhice incapacitante; c) na juventude não remunerada pelo despreparo e incapacidade para o exercício de atividade rentável; d) na prisão do alimentante em face da prática de delito, enquanto durar a pena.

Logo, para não haver uma incorreta aplicação da pensão alimentícia, os tribunais brasileiros passaram a corrobora com o entendimento acima, fundamentando que a pensão avoenga é subsidiaria, e havendo a falta de elementos probatórios que justifique a incapacidades dos genitores, ou se os mesmos dispões de condições para adentrar no mercado de trabalho, não justifica encarregar os avós de arca com a referida obrigação. nessa percepção o Tribunal de Santa Catarina em 2017 no processo de nº 0052189-87.2006.8.24.005, julgou da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA CONTRA OS AVÓS PATERNOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS NETOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSIBILIDADE DA GENITORA DE PROVER O SUSTENTO DOS INFANTES. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO E PLENA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DECLÍNIO DO PADRÃO FINANCEIRO APÓS O FALECIMENTO DO GENITOR. ALIMENTOS AVOENGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ELEVAR O PADRÃO FINANCEIRO DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E IMPRÓVIDO. "A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação - ou de cumprimento

insuficiente - pelos genitores" (REsp 831.497/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010). Por se tratar de pessoa jovem, com plena capacidade para o trabalho e cujas aptidões a permitem atuar nos mais diversos seguimentos, haja vista que ora trabalha como apresentadora, ora como "chef" de cozinha, ora promotora de eventos, ora revendedora de artigos de vestuário e cosméticos etc, poderá, então, fazer frente ao sustento dos filhos com os frutos do seu próprio labor. (TJ-SC - AC: 00521898720068240005 Balneário Camboriú 0052189-87.2006.8.24.0005, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 24/08/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

Vejamos que a pensão avoenga também tem um caráter transitório, devendo perpetuar até cessar a total incapacidade dos principais alimentantes, essa pensão não é instituída sem fundamento, o seu devido fim é que o menor não seja desamparado, fazendo jus aos ditames constitucionais, Então, havendo a real incapacidade dos genitores, para que não ocorra o risco na subsistência do alimentado, é plausível que os avós sejam os responsáveis em proporcionar os alimentos para seus netos, ao passo que são o parentes de grau mais próximo, respeitando a linha sucessória delineada no art. 1.696 do código civil (BRASIL, 2002).

Está com dúvidas sobre seus direitos
Receba orientações iniciais e entenda o que fazer no seu caso.

Assim, é possível considerar que o instituto da pensão alimentar é um direito de caráter quase absoluto da criança ou adolescente, sendo necessário para a satisfação de uma vida mínima justa e digna, devendo respeitar as necessidades básicas do ser humano, e respeitando os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal.

2.2 DA OBRIGATORIEDADE DOS AVÓS NA PENSÃO ALIMENTAR: ANALISE DO ART. 1698 DO CÓDIGO CIVIL

Dito anteriormente que entre os requisitos para que a obrigação alimentar recaia sobre os avos, perfaz necessária a incapacidade dos genitores, e o vínculo parentesco, ambos de fácil constatação, além disso, tem respaldo no princípio da solidariedade família e

também no art. 1.696 do Código Civil, que o direito de prestação dos alimentos é extensivo a todos os ascendentes.

Analisa-se que o art. 1.698 do Código Civil, assegura que o alimentado não vai ficar sem o devido auxílio, visto que, na impossibilidade total ou parcial do principal alimentante, é permissivo o chamamento de parentes de grau mais próximo, nesse termo, perfaz a possibilidade da convocação dos avós para compor a lide, assim, alcançando a finalidade de complementar na pensão alimentícia.

A segunda parte deste artigo permite a possibilidade de fracionamento da obrigação alimentícia, assim, havendo várias pessoas obrigadas a arca com a pensão alimentar, todas, devem concorrer com base nos seus rendimentos nesse tramite Rizzardo (2018, p. 668):

Cristiana Sanches Gomes Ferreira considera 'conjunta' a obrigação alimentar: "A obrigação de alimentos não é solidária, mas sim conjunta, de acordo com o artigo 1.698 do Código Civil. Intentada a ação contra algum parente dos coobrigados, portanto, poderá este chamar à lide os demais coobrigados. Trata-se de obrigação conjunta, posto que divisível entre os parentes à proporção de suas efetivas possibilidades".38

Nesse ponto, com essa possibilidade de fracionar os alimentos, assegura-se a real condição dos avos, pois ao serem chamados para integrar a lide, até serem ouvidos no decorre do processo, não será "possível" saber qual a real condição financeira dos mesmos. Então se apenas os avós paternos forem incluídos na demanda, e esses não têm condições de suportar o valor da pensão de forma total, existe a possibilidade de dividir a pensão entre os avós integrados na lide, e o genitor do menor, Exemplificando, Luz (2009, p. 299):

A regra, como se observa, é de alto significado prático, o que importa dizer, por exemplo, que, necessitando o alimentando de R$ 500,00 para sua mantença e podendo o pai somente contribuir com R$ 250,00, poderá o alimentando voltar-se contra os avós para buscar a complementação dos R$ 250,00 faltantes.

Ocorre que esse mesmo artigo afirma que se a ação for proposta em face de apenas um dos responsáveis a arca com os alimentos, os demais responsáveis poderão ser chamados para integra a lide, observa-se que esse termo ''poderão'' tem gerado uma ''divergência'' na jurisprudência brasileira, pois, essa palavra dá sentido de que o autor ao

adentrar com a ação, tem a faculdade de escolhe qual dos parentes será o responsável para arca com os alimentos.

Desta forma, através dessa análise do (art. 1698 do Código Civil), irá ser observado os efeitos processuais gerados na ação alimentar proposta em face dos avós.

2.3 DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS: A RESPONSABILIDADE DOS AVÓS.

Com a chegada da lei nº 11.804/08, que visa garantir que o alimentado tem o direito aos alimentos antes do seu nascimento, assim, o principal objetivo dessa lei é assegurar que a mulher que esteja durante o período gestacional, tenha o devido auxilio do genitor da futura criança que estar por vim, pois a gestação gera uma serie de constantes gastos, com idas e vindas, no hospital, transporte, exames, enxoval, então a pensão gravídica garanti ao nascituro e gestante um período de gestação digno com os padrões constitucionais, que tem entre suas bases o princípio da dignidade da pessoas humana, conforme Tartuce, (2014, p. 506):

Os citados alimentos gravídicos, nos termos da lei, devem compreender os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam delas decorrentes, da concepção do parto, inclusive, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere como pertinentes (art. 2, caput).

Essa lei passou a preencher uma lacuna, visto que a lei de alimentos, não disponibilizava sobre a obrigação de prestação de alimentos durante a gestação, dessa forma, a gestante teria um amparo legalmente positivado, que garantiria esse direito, e também facilitaria ao judiciário decidir a ação, ao se deparar com uma situação semelhante.

Ocorre que os alimentos gravídicos também devem visar ao binômio: necessidade e possibilidade do alimentante. Estando o alimentante totalmente impossibilitado de arca com essa obrigação, quem seria obrigado a fornece a pensão gravídica.

Assim, observa-se que a lei dos alimentos gravídicos em seu parágrafo único, de seu art. 2, diz que os alimentos e despesas delineadas serão custeados pelo futuro pai de acordo com a Lei 11.804. No entanto não disciplina quem será o responsável na sua total ou parcial incapacidade, deste modo, recorresse ao Código Civil, supletivamente, em seu artigo 1.696, que torna possível essa obrigação estendo aos ascendentes de grau mais próximo, ou seja, aos avós. Observa-se a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. O requisito exigido para a concessão dos alimentos gravídicos é de que a parte requerente demonstre "indícios de paternidade", nos termos do art. 6º da Lei n.º 11.804/08. O exame de tal pedido, em sede de cognição sumária, sob pena de desvirtuamento do espírito da Lei, não deve ser realizado com extremo rigor, tendo em vista a dificuldade em produzir prova escorreita do alegado vínculo parental. Precedentes. Caso em que as mensagens trocadas entre as partes conferem grande verossimilhança à alegação de paternidade do réu, e autorizam o deferimento dos alimentos gravídicos, em sede liminar. Na peculiaridade do caso concreto, o réu é menor de idade, tem apenas 15 anos, e projeta-se seja sustentado pelos seus próprios pais, também corréus na demanda. Considerando essa circunstância, entende-se que, ao menos em sede liminar, e para não fulminar o direito aos alimentos gravídicos, cabe fixação contra os avós paternos, na quantia postulada pela parte recorrente (50% do salário-mínimo), que não representa quantia excessiva ou desproporcional. Depois de instaurado o contraditório na origem, todos os temas, tanto a fixação, quanto o valor dos alimentos, poderão ser revistos pelo juiz de... primeiro grau. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70080227812, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 04/04/2019). (TJ-RS - AI: 70080227812 RS, Relator: Rui Portanova. Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019).

Em relação à aplicação da regra do art. 1698 do Código Civil, permitindo a divisão dos alimentos gravídicos, entre genitor e avos, ou na total incapacidade do genitor, os avos seriam os responsáveis pelo valor total do encargo, lembrando que ainda fica a deixa, devido a palavra poderão do referido artigo, como já dito anteriormente, quem deve compor a demanda, os avós paternos, ou os avós paternos e maternos conjuntamente.

Os alimentos gravídicos têm praticamente a mesma função da pensão alimentícia, a diferença é que o primeiro ocorre antes do nascimento da criança, e o último após seu nascimento com vida, mas ambos visam garanti o seu direito de receber o suficiente para o seu existencial, tanto que pode ser garantido pelos seus genitores e em último caso pelos avós paternos ou maternos.

DO LITISCONSÓRCIO NA PENSÃO AVOENGA: E QUEM DEVE FIGURAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO?

Primeiramente esclarecemos que o litisconsórcio ocorre na pluralidade das partes num único processo, seja no polo passivo ou ativo da demanda, com o objetivo de alcançar a economia processual, visto que haverá apenas uma ação para julgar aquele litígio e, consequentemente, uma única instrução e sentença.

Dentre as diversas formas de litisconsórcio, destaca-se o litisconsórcio necessário e facultativo. O primeiro, como condiz com o próprio nome, tem a sua formação de caráter obrigatório, de modo que o processo não vai adiante, na ausência de todos os litisconsortes. E o litisconsórcio facultativo que tem sua formação de forma opcional.

Neste passo, o art. 114 do Código de Processo Civil de 2015 regula duas hipóteses em que o litisconsórcio será necessário. A primeira é quando houver prévia disposição da lei, e a segunda hipótese ocorre pela natureza da respectiva relação controvertida, assim, a sentença só vai obter eficácia com a devida citação de todos os litisconsortes que devam integra a lide. Corroborando com a fala, Câmara, (2019, p. 549):

O litisconsórcio é necessário quando sua formação é essencial para que o processo atinja seu fim normal. Resulta a necessariedade do litisconsórcio do fato de em alguns casos a legitimidade *ad causam* ser plúrima, isto é, pertencer a um grupo de pessoas, de modo tal que só estará presente no processo a parte legítima se todo o grupo, com todos os seus integrantes, estiver reunido no processo.

Ressalta-se que o litisconsórcio necessário se divide em 02 (duas) espécies, a primeira é o simples, que nas palavras de Marcelo ribeiro é aquele em que pode ocorrer decisões diversas, mesmo que é permissivo que no caso concreto as partes tenham o mesmo destino. (RIBEIRO, P. 135), a segunda hipótese ocorre é o unitário, que ocorre quando o juiz ao proferir uma decisão em que haja uma pluralidade das partes, essa decisão deve ser igualitária para todos os litisconsortes.

Então na ação de alimentos, via de regra há um litisconsórcio facultativo, apenas é necessário a figura do genitor do menor no polo passivo da demanda, mas quando proposta em face do pai da criança e avô paternos e maternos, e a decisão for diferente para ambos, acontece a hipótese de litisconsórcio necessário simples.

Ocorre que antes de adentra no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vamos analisar o entendimento antes da vigência do atual código civil, primeiramente observa-se o (art. 397 e 398 do código civil de 1916) o primeiro tem praticamente a mesma redação do art. 1696 do código civil atual, mas a grande mudança foi no 398, em comparação com o atual:

Art. 398. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes guardada a ordem da sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos, como unilaterais.

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

Nesse seguimento, percebe-se que o artigo do Código civil de 1916 não abre a possibilidade de um litisconsórcio necessário, pois é bem claro ao estabelecer uma ordem sucessória logica sem demais questionamentos, tudo isso com o devido fim de não gerar conflitos jurisprudenciais e doutrinários, porém é inerte em relação a divisão da pensão alimentar. Os entendimentos do STJ antes do código civil de 2002:

AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR NETOS CONTRA O AVÔ PATERNO. CITAÇÃO DETERMINADA DOS AVÓS MATERNOS. INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. O CREDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE AJUIZAR A AÇÃO APENAS CONTRA UM DOS COOBRIGADOS. NÃO SE PROPONDO A INSTAURAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO IMPRÓPRIO ENTRE DEVEDORES EVENTUAIS, SUJEITA-SE ELE AS CONSEQÜÊNCIAS DE SUA OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO."(Resp. 50153/ RJ, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, publicado no DJ de 14.11.1994).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA AVÔ PATERNO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS AVÓS MATERNOS. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. ORIENTAÇÃO DA TURMA. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Resp 261772/ SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, publicado no DJ de 20.11.2000).

Conforme esses julgados, vejamos que não havia a necessidade da inclusão dos avós maternos no polo passivo, visto que o artigo 398 do Código Civil não abria essa possibilidade, prevalecendo o litisconsórcio facultativo na ação de alimentos avoengos, então a grande questão nessas decisões é que, a ação de alimentos é proposta pelo menor que em regra é devidamente representado pela sua genitora, que logicamente não iria botar no polo passivo os avós maternos, em virtude de serem seus genitores.

Apesar da modificação com o advento do código civil de 2002, os tribunais ainda permaneceram com o entendimento de que o litisconsórcio na pensão em face dos avós é de caráter facultativo, visto que no artigo 1698 do código civil ao afirmar poderão as demais pessoas ser chamadas a integrar a lide dá um sentido de que o litisconsórcio é facultativo, cabendo ao autor da ação escolhe sobre quais avós serão os responsáveis para pagar a pensão alimentar Observemos esse entendimento do ano de 2018 do Tribunal do Rio Grande do Sul:

ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. CHAMAMENTO À LIDE DOS AVÓS MATERNOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os avós maternos e paternos, pois a obrigação alimentar é divisível e não solidária. 2. Caso o parente obrigado prioritariamente a prestar alimentos não tenha condições de suportar sozinho o encargo, podem ser chamados a concorrer os de grau imediato e os demais obrigados. Inteligência do art. 1.698 do CC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70075643213, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 25-04-2018)

O respectivo entendimento sustenta a inexistência do litisconsórcio sob a alegação da não solidariedade da obrigação alimentar, como já dito anteriormente é claro que a obrigação dos avós é subsidiaria, sendo apenas cabível na impossibilidade do genitor em prover com o sustento do menor, mas o fato dessa obrigação ser divisível, não quer dizer que o litisconsórcio deva ser facultativo em relação aos avós do menor, observa-se que esse tipo de decisão gera uma aplicação injusta ao alimentante.

Exemplificando, a ação de alimento é proposta em face do genitor, se o mesmo comprova a sua incapacidade, então o autor vai requere a inclusão dos avós paternos nessa demanda, o juiz então julga procedente a ação, e responsabilizar os avós paternos a

arca com os alimentos, enquanto isso os avós maternos que possivelmente estão vivendo em melhores condições, não serão responsabilizados. Então, nesses casos não há uma correta aplicação da divisibilidade dos alimentos, pois essa divisão é para facilitar a questão da possibilidade do alimentante, e permiti que o alimentado receba a devida prestação.

Nesse contexto, Rolf Madaleno informa que para que haja uma fixação equitativa, deve trazer todos os devedores ao processo, assim todos vão relatar sobre as suas devidas possibilidades, assim atendendo as necessidades do menor. (MADALENO, 2013, p. 881).

O Superior Tribunal de Justiça, que na vigência do Código Civil de 1916, entendia que nesses casos o litisconsórcio era facultativo. O atual prevalece o entendimento de que o litisconsórcio é de natureza necessária, a primeira decisão do STJ que foi de encontro com essa vertente, foi o REsp 658.139/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 13/03/2006, sob o argumento de que a obrigação alimentar não tem caráter de solidariedade, no sentido que sendo varias pessoas obrigadas a arcar com os alimentos, todos devem concorre com base nos seus ganhos, e quando houver a impossibilidade do alimentante principal, a obrigação subsidiaria deve ser dividida entre os avós paternos e maternos na proporção de seus recursos. A partir desse entendimento o STJ passou a entender que há sim um litisconsórcio necessário na ação de alimentos em face dos avós. Conforme os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DOS ALIMENTOS PRESTADOS PELO GENITOR. COMPLEMENTAÇÃO. AVÓS PATERNOS DEMANDADOS. PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE AVÓS PATERNOS E MATERNOS. CABIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1.698 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. I. Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, à luz do Novo Código Civil, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes. II. Recurso especial provido. (REsp 958.513/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 01/03/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS SUBSIDIÁRIOS. AVÓS. INCLUSÃO DOS AVÓS MATER-

NOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO RELATIVA À LEGITIMIDADE. 1. Não há que se declarar ilegitimidade de parte ou vício de representação se uma das partes que apresentou o recurso especial se encontrava regularmente representada e o provimento de sua pretensão aproveita ao colitigante. Não se revela o interesse em recorrer no ponto. 2. Não há que se falar em aplicação do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça se não houve pronunciamento ou análise de qualquer questão fática da lide, tendo a decisão agravada incursionado unicamente em tema de direito, de forma abstrata. 3. Nos termos do Código Civil e da mais recente jurisprudência do STJ, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1073088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 05/10/2018)

Sabe-se que os alimentos tem um caráter de urgência, há uma necessidade de que aquele determinada decisão que obriga o alimentante a arca com essa obrigação seja devidamente cumprida, seja pelo pai do menor, ou por seus avós, mas como já dito acima a obrigação dos avós é de caráter subsidiário, então ressalto a importância do atual entendimento do STJ, pois, olhando por um lado logico, quanto mais pessoas forem obrigadas a prestar os alimentos, há chance de cumprimento da decisão aumentar, e também diminuir o prejuízo a própria subsistência do alimentante.

Nota-se o exemplo, o genitor do menor arca com 20 (vinte por cento) do salário mínimo vigente, mas por algum motivo alheio a sua vontade, não tem mais condições fornecer os alimentos, então, logo serão chamado os avós paternos, que são assalariados, e ainda tem outros gastos com alimentação, medicamentos, e entre outros, então se ambos os avós forem responsabilizados, cada um, em regra vai se responsável por 10 (dez por cento) da pensão alimentar, logo o risco do menor não ser devidamente amparado, vai ser menor.

Talvez o grande porém, seja que aqui no brasil, na maioria dos casos, a genitora junto com seu filho, quando ocorre a dissolução conjugal, volta a morar na casa dos pais, então de certo modo, os avós maternos passam a cuidar do seu neto, sem precisamente

ser necessário uma imposição judicial, entretanto, essa situação deve ser esclarecida na ação de alimentos, e nesses casos, pode aplicar a pensão avoenga apenas em face dos avós paternos, mais isso não tira a importância de que deve haver o litisconsórcio necessário nesse tipo de ação.

Outro ponto, em que a regra é a seguinte, o genitor e genitora do menor, como já dito acima, tem o dever de manter seus filhos, o propiciando moradia, alimentação, saúde e educação, importante frisar, que teoricamente não há uma responsabilidade maior do genitor ou genitora, a ambos tem os mesmos deveres, pois estão no mesmo grau de parentesco, e os avós também estão equiparados como ascendentes de 2º grau, tanto os maternos e paternos, percebe-se que não há um grau superior ou inferior dos avós de 2º grau, logo quando um desses passam a ser os responsáveis pela alimentação dos seus netos, não há motivos para que os demais avós não sejam necessariamente incluídos na demanda, Azevedo (2013, p. 333):

Na falta dos pais, a obrigação dever ser cumprida pelos avós, bisavós, trisavós e etc.; uns em falta de outros. Desse modo, se existem vários ascendentes de mesmo grau, são obrigados todos em conjunto, em razão do que 'a ação de alimentos deve ser exercida contra todos, e a quota alimentar é fixada de acordo com os recursos dos alimentantes e as necessidades do alimentário. Assim, intentada a ação, o ascendente (avó, bisavó etc.) pode opor que não opor que não forma chamados a prestar alimentos os outros ascendentes do mesmo grau. Se algum dos ascendentes não tem meios com que alimente o descendente, o outro dos ascendentes do mesmo grau os presta''. Ante qualquer recebimento alimentar precário ou insuficiente, pode ser pedida complementação.

Por fim, conclui-se a necessidade do alimentando prevalece sobre diversas situações, diante dessa importância, nasce a possibilidade de responsabilizar os demais parentes de grau mais próximos, que em grande parte são os avós, e tendo em vista que ambos são do mesmo grau de parentesco, prevalece a possibilidade do litisconsórcio necessário simples, como forma de atender a necessidade do alimentante, e evitar um que o mesmo seja desamparado totalmente, e que os avós, que respondem de forma subsidiaria, não tenham o risco de ver prejudicada sua própria subsistência.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise do instituto da pensão alimentícia, não só no contexto da legislação atual, mas sim, no ponto de vista histórico

desse instituto, que no Brasil teve uma evolução positiva, a começar pelo advento do Código Civil de 1916, que estendeu que a prestação dos alimentos é reciproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, e com base nessa legislação, passaram a ser criadas outras leis que abrangeram de uma forma mais contundente a obrigação alimentar.

A Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2.002 trouxeram diversos avanços no campo da pensão alimentícia, abordando o tema de forma mais abrangente, trazendo um rol de novas possibilidades, como a hipótese de fracionamento da pensão, delineada no artigo 1698 do código civil, que permite uma divisão dos alimentos, afirmando, que na impossibilidade de um dos alimentantes, poderá esse valor ser dividido entre os demais credores, assim trazendo uma maior probabilidade do alimentado não ficar sem os alimentos.

Além do mais, o objetivo foi esclarecer o quão é importante à prestação alimentar em favor da criança ou adolescente, que deve ser prestada pelos seus ascendentes de 1º grau, que tem o dever legal de cumprir esse papel, fornecendo alimentação, educação, saúde e afeto, assim, assegurando ao menor um crescimento adequado, conforme os ditames constitucionais.

E devido à importância do instituto da pensão alimentar, que tem o devido fim de garantir a sobrevivência do menor, é de suma importância que na impossibilidade dos genitores, mesmo que de forma subsidiaria, perfaz necessário a inclusão dos avós no polo passivo da ação, em razão da necessidade do menor, que não pode ficar desamparado, e também do próprio princípio da solidariedade familiar.

Mas, essa obrigação apenas não é limitada aos avós, ela vai, numa escada familiar, sendo transmitidas a todos os parentes de grau mais próximos, funcionando da seguinte maneira, na impossibilidade dos pais, recai sobre os avós, se esses também se encontram impossibilitados, recai para os bisavós, e assim sucessivamente. Ressaltando que a doutrina e jurisprudência majoritária, permite sem questionamentos, que os avós sejam responsabilizados, quando comprovada a total incapacidade dos genitores, porém, devido a possibilidade de divisão dos alimentos, os avós podem também integra a lide, mesmo que a impossibilidade do genitor não seja total, e sim parcial.

Nesse rumo, percebe-se que necessidade alimentar não deve ser pautada por quem paga, mas sim por quem recebe, representando para o alimentado maior provisiona-

mento tantos quantos coobrigados houver no polo passivo da demanda. Utilizando- se do princípio do melhor interesse do menor.

Diante do exposto no artigo 1.698, a questão da formação litisconsorcial na ação de alimentos que envolva no polo passivo os avós, ganhou vários entendimentos jurisprudenciais, cada um entendendo de uma forma, tudo isso devido ao verbo "poderão", e devido a essa palavra, até hoje alguns tribunais entendem que o litisconsórcio nesse tipo de ação é de natureza facultativa. Portanto, sendo facultativo, gerar uma imposição injusta aos avós, pois o autor pode escolher quem ele bem quiser para figurar o polo passivo, enquanto o restante dos avós fica sem a devida responsabilidade.

Deste modo, em consonância com o atual entendimento do STJ, defende-se que nesses casos, deve-se aplicar a ideia do litisconsórcio necessário simples, como meio de garantir a completa prestação dos alimentos, pois, dividindo os alimentos entre os avós paternos e maternos, há uma maior probabilidade de cumprimento da prestação alimentícia.

Por fim, concluo que a formação do litisconsórcio defendido nesse trabalho é de natureza necessária e simples, visto que, os alimentantes que figuram no polo passivo da ação, não precisam necessariamente de uma decisão igualitária para todos, cada um será responsável de acordo com seus rendimentos, pode ser que os avós paternos sejam obrigados a pagar por mais da metade da pensão alimentar, o resto ficara para os avós paternos, mais tudo isso dependera da análise no caso concreto, por isso a importância do litisconsórcio necessário.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Álvaro Villaça. **Curso de Direito Civil, Direito de família.** Editora Atlas. 2013.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da Republica Federativa do Brasil**.

Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/constituição/constituição.htm. Acesso em: 09 jun.2020.

BRASIL. **Código Civil**, Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 09 jun.2020.

BRASIL. **Código de Processo Civil**, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 09 jun.2020.

BRASIL. **Alimentos Gravídicos**, Lei nº 11.804, 05 de novembro de 2008. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ _ato2007-2010/2008/lei/l11804.htm. Acesso em: 09 jun.2020.

BRASIL**. Ação de Alimentos**, Lei nº 5.478, 25 de julho de 1968. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/LEIS/L5478.htm. Acesso em: 09 jun. 2020.

BRASIL. **Divórcio**, Lei nº 6.515. 26 de dezembro de 1977. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ /ccivil_03/leis/l6515.htm. Acesso em 09 jun. 2020.

BRASIL. **Investigação de Paternidade**, Lei nº 12.004. 29 de julho de 2009. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ /ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12004.htm. Acesso em 09 de jun. 2020.

BRASIL**. Código Civil**, Lei nº 3.071, 01 de janeiro de 1916. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ leis/L3071.htm, Acesso em: 09 jun. 2020.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 396, 20 de novembro de 2017. Disponível em:

http://www.Scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27596%27).sub.

CAHALI, Yussef Said. **Dos alimentos.** 6 ª. Ed., rev., atual. eampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 8ª ed. são Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011.

FARIAS, Cristiano Chaves de. **Direito das Famílias**. 2ª ed. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro**, vol. 6º. **Direito de Família**. 16 ª ed. Editora Saraiva jur, 2019.

MALUF, carlos, adriana. **Curso de Direito de Família**. 2 ª ed. Editora Saraiva, 2019.

MADALENO, Rolf. **Curso de Direito de Família**. 5ª ed. rev., atual. eampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

MADALENO, Rolf. **Direito de Família**. 9ª d. Editora Forense, 2019.

MADALENO, Rolf. **Manual de Direito de Família**. 3ª ed. Editora Forense, 2020.

LUZ, Valdemar P. da**. Manual de Direito de Família**. 1ª ed. Barueri, São Paulo. Editora Manole, 2009.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito de Família**. 10ª ed. Editora Forense, 2018.

RIBEIRO, Marcelo. **Processo civil**, 2 ª ed. Editora Método, 2019.

STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 658.139 RS 2004/0063876-0. Relator: Ministro Fernando Gonçalves, DJ: 13/03/2006. **JusBrasil**, 2006. Disponível em: https://stjjusbrasil.com.br /jurisprudencia/7173791/recurso-especial-resp-658139-rs-2004-0063876-0/inteiro-teor-12902301.

STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 1073088 SP 2017/0063599-6. Relator: Ministra: Maria Isabel Gallotti, DJ: 05/10/2018. **JusBrasil**, 2018. Disponível em: https://stjjusbrasil.com.br/jurisprudencia/568203366/agravo-em-recurso-especial-aresp-1073088-sp-201...

STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 261772 SP Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira DJ: 20/11/2000. **JusBrasil,** 2000. Disponível em:

https://stjjusbrasil.com.br/jurisprudencia/330326/recurso-especial-261772-sp-2000-0055111-2/inteiro-...

STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp: 958153, SP Relator: Aldir Passario Junior, DJ: 01/03/2011. **JusBrasil**, 2011. Disponível em: https://stjjusbrasil.com.br/jurisprudencia /18446243/recurso-especial-resp-958513-sp-2007-0129470-0/inteiro-teor-18446244

STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 50153, RJ Relator: Ministro Barros Monteiro, DJ: 14/11/1994. **JusBrasil**, 1994. Disponível em: https://stjjusbrasil.com.br/jurisprudencia /560415/recurso-especial-resp-50153/relatorioevoto-9348914?ref=juris-tabs

TJRS. **AGRAVO DE INSTRUMENTO:** 700756432013, RS Relator: Sergio Fernando de Vasconcellos Chaves, DJ: 27/04/2018. JusBrasil, 2018. Disponível em: https://stjjusbrasil.com.br/jurisprudencia /574591223/agravo-de-instrumento-ai-70075643213-rs?ref=juris-tabs

TJRS. **AGRAVO DE INSTRUMENTO:** 70080227812, RS Relator: Rui Portanova, DJ: 04/04/2019. JusBrasil, 2018. Disponível em: https://stjjusbrasil.com.br /jurisprudencia/697343383/agravo-de-instrumento-ai-70080227812-rs

TARTUCE, Flavio. Direito Civil, vol. 5º **Direito de Família**. 9 ª ed. Editora método, 2014.

WALD, Arnoldo. **Curso de Direito Civil Brasileiro: O novo Direito de Família**. 12. Ed., rev., ampl. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

1. Discente do curso de Direito na Fundação Educacional Baixo São Francisco - Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: jonathanfausto169@gmail.com ↑
2. Professor de graduação e pós-graduação do curso de Direito na Fundação Educacional Baixo São Francisco - Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: ↑

Envie as suas dúvidas

Receba orientações iniciais e entenda o que fazer no seu caso.

Descreva o que aconteceu e o que você gostaria de saber...